

1503651-98.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/09/2022
... sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EM DECORRÊNCIA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADO.
[...] 4. Não se pode admitir que meras dificuldades financeiras justifiquem o cometimento do crime de tráfico de drogas, que tem por bem jurídico tutelado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503651-98.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294988/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21093797 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6163/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2294988 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WASHINGTON LUÍS DE JESUS BRANDÃO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

WASHINGTON LUÍS DE JESUS BRANDÃO JUNIOR está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Notificado (fls. 4852), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 4853/4855).

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 4858/4859) e o acusado foi citado (fls. 4891).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 4892 e 9559).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 9569/9574).

A defesa suscitou a ilegalidade da prova produzida. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima legalmente cominada e das benesses legais (fls. 9578/9600).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, não se verifica ilegalidade na expedição do mandado de busca e apreensão.

A ordem foi determinada após decisão fundamentada que acatou as razões da autoridade policial sobre as denúncias recebidas e os motivos que impossibilitavam eventuais diligências prévias (autos em apenso). Ressalte-se que não há vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades sobre fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão às práticas ilícitas. Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate aos crimes. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO NULIDADE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

... II - Ademais, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes). ... Recurso ordinário desprovido”.

(STJ - RHC: 79374 SP 2016/0321352-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017)

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/12), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fls. 18/19 e 22/23), informações (fls. 41/45), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 158/165), laudos periciais (fls. 166/169 e 4900/9549) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

O réu optou por permanecer em silêncio perante a autoridade policial (fls. 12) e não compareceu em juízo para ser interrogado, apesar de intimado.

O policial civil Filipe relatou que foram recebidas informações sobre a prática de tráfico no endereço do réu e expedido mandado de busca e apreensão. Em cumprimento à ordem judicial, foram localizadas porções de maconha e de cocaína em cima da cômoda no quarto do acusado, que, segundo ele, seria toda a droga que havia ali.

Todavia, em continuação às buscas, encontrou, dentro de um saco de ração, uma sacola de plástico na qual estavam armazenados vários pinos de cocaína. Questionado, o acusado se limitou a dizer "perdi" e que costumava armazenar as drogas naquele local. Na delegacia, foi vistoriado o celular do réu e visualizou mensagens sobre transações de entorpecentes com dois indivíduos.

O policial civil Evandro confirmou o encontro de várias porções de cocaína em um saco de ração, e porções de maconha em cima da cômoda. Aduziu que o réu disse que perpetrava o tráfico por necessidades financeiras e que tinha um irmão que também estava preso por tal conduta.

Pois bem.

O réu não apresentou sua versão sobre os fatos, pois permaneceu em silêncio na delegacia e não compareceu em juízo para ser interrogado.

Não há dúvida quanto à prática, pelo acusado, do crime que lhe foi imputado.

Os policiais civis relataram o cumprimento do mandado de busca e a apreensão de significativa quantidade de drogas na residência do acusado, além de balança de precisão e do celular dele.

Os dados extraídos do aparelho apreendido (laudo de fls. 4900/9549) explicitam o exercício do comércio espúrio pelo acusado. Vale transcrever algumas conversas:

Fls. 314/315 - entre o acusado e o interlocutor "Neno", no qual Neno pergunta a Washington, dois dias antes da prisão do acusado:

"Ae vc vai fortalece na queles pino?".

Fls. 9515 - entre "Bal" e o acusado, em que "Bal" solicita que Washington entregue as drogas em sua casa:

"Traz 20 no dinheiro em casa, quizer trazer 3, parceiro vai paga 2, ai vai vim busca aqui, pq muie dele é moiado".

Fls. 9522 - entre Washington e "Adriano", na qual o réu avisa ao interlocutor que: "Boa não chegou ainda mano que trazia foi preso".

Não prospera a alegação defensiva acerca da incerteza do uso do celular por Washington, pois o réu deixou inequívoca sua identidade em conversas com sua namorada Chirley, ao informar seu nome completo para participar de uma reunião escolar do filho dela (fls. 6359) e seu endereço (fls. 7575).

A finalidade de entrega a terceiros restou comprovada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da localização de balança de precisão com resquício de cocaína (fls. 166/169), somados às diversas mensagens extraídas do celular dele.

A alegação de dificuldade financeira, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, já que o réu deveria buscar meios lícitos para sua subsistência.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EM DECORRÊNCIA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADO.

[...] 4. Não se pode admitir que meras dificuldades financeiras justifiquem o cometimento do crime de tráfico de drogas, que tem por bem jurídico tutelado a saúde pública, e é de especial gravidade, tanto que equiparado a crime hediondo. 5. Recurso desprovido".

(TRF-3 - Ap: 00012228420084036181 SP, Relator: JUIZA CONVOCADA SILVIA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2011, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1

DATA:02/12/2011)

Nesse contexto, suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado da denúncia, de rigor a sua condenação.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, a pena-base merece aumento, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, em virtude da significativa quantidade de cocaína apreendida. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho a reprimenda no patamar anteriormente fixado.

Por fim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime de 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para

a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, WASHINGTON LUÍS DE JESUS BRANDÃO JUNIOR à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade. Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA